

1502472-06.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... e tem um processo em andamento por tráfico.

O réu Evandro, na fase policial (fls. 08) confessou que colaborava com o tráfico, afirmando que auxiliava o acusado José Francisco na função de "olheiro". Negou estar vendendo drogas no local. Em juízo, negou a prática do crime, alegando que é usuário e fazia reciclagem. Foi comprar drogas, mas não estava com dinheiro, apenas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1502472-06.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502472-06.2021.8.26.0537 Controle nº 25/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS e EVANDRO BARROMEO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, c.c. art. 29, "caput", do Código Penal, porque no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 13:30 horas, na Passagem Tião Carreiro, altura do n.º 10, Bairro Vila Nogueira, agindo em concurso, unidos em desígnios com identidade de propósitos e divisão de tarefas para o fim comum, guardavam, para fins de entrega a consumo de terceiros, cocaína, "crack" e maconha, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

As prisões em flagrante foram convertidas em prisões preventivas por decisão do juiz de plantão (fls. 82/85), tendo sido reapreciadas em 28.03.22 e mantidas (fls. 204/205).

Foram apresentadas defesas prévias (fls. 154/172 - réu Evandro; fls. 187/188 - réu

José Francisco), sendo recebida a denúncia em 28.03.22 (fls. 204/205). Os réus foram interrogados no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais. A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela quantidade de drogas, aplicação da redução do art. 33 para o réu Evandro que é primário, regime aberto e quanto ao acusado José que é reincidente, afastada a redução do art. 33, §4.º e regime fechado, além do perdimento do dinheiro apreendido.

O Defensor Público requereu a absolvição do acusado José Francisco por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação a compensação da confissão extrajudicial com a reincidência, detração e fixação de regime semiaberto.

O defensor do réu Evandro requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para art. 28 ou caso de eventual condenação a redução do art. 33, §4.º no máximo, fixação de regime aberto, com as substituições legais, por ser primário, e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido de exame de dependência toxicológica do réu Evandro foi indeferido a fls. 205. A defesa novamente reiterou o pedido após o interrogatório, o que foi indeferido pelos mesmos fundamentos. Diante do interrogatório judicial e da confissão extrajudicial que era "olheiro" nada há nos autos que demonstre que não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento, pelo que mantenho o indeferimento do exame de dependência toxicológica.

Aplico a "emendatio libelli" quanto ao réu Evandro para constar que a qualificação legal correta é do art. 37 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que conforme descrito na denúncia trabalhava apenas como "olheiro" não tendo qualquer responsabilidade sobre a droga apreendida.

O acusado José Francisco, fase policial (fls. 07), confessou a prática do crime, dizendo que estava traficando, que era usuário de "crack" e ganhava 15 % do valor das vendas. Em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que estava fazendo serviço de limpeza para uma moradora, inclusive com vassoura e foi abordado. Os policiais acharam as drogas e o incriminaram. Recebeu R\$30,00 por esse serviço de limpeza, mas não sabe informar o nome da moradora. É dependente químico. Não conhecia os policiais que o abordaram, nem o Escrivão e Delegado. Nunca foi condenado e tem um processo em andamento por tráfico.

O réu Evandro, na fase policial (fls. 08) confessou que colaborava com o tráfico, afirmando que auxiliava o acusado José Francisco na função de "olheiro". Negou estar vendendo drogas no local. Em juízo, negou a prática do crime, alegando que é usuário e fazia reciclagem. Foi comprar drogas, mas não estava com dinheiro, apenas com o saco de reciclagem que pretendia vender por R\$5,00 para comprar "crack". Tem um furto em andamento. A prisão o livrou das drogas por 4 meses. Perdeu emprego em razão das drogas e precisa de um tratamento.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 04/06), relataram que receberam uma denúncia anônima de tráfico, as características dos réus (dois homens, um trajando camiseta azul, calça preta e tênis preto e outro trajando camiseta branca com listras, bermuda e chinelos) coincidiam. Falaram que um dos acusados notou a aproximação deles e avisou o outro, que estava varrendo o chão, mas não tiveram tempo de se evadir. Narraram que abordaram o réu José Francisco, que este confessou que estava vendendo drogas e apontou o local onde as guardava (embaixo de um papelão, dentro de uma sacola preta, ao lado de onde estava). Afirmaram que o acusado Evandro negou estar traficando e que o réu José Francisco informou que aquele o estava ajudando, prestando informações como "olheiro". Informaram que dentro da sacola indicada por José Francisco encontraram 36 porções de maconha, 94 pedras de "crack" e 47 invólucros de cocaína. Declararam que no bolso do réu José Francisco localizaram a quantia de R\$ 30,00, em cédulas trocadas.

Marcus (policial), em juízo, afirmou que seu parceiro recebeu uma ligação anônima

dando as características de dois homens que traficavam no local. Disse que avistaram os réus, cujas características coincidiam. O homem de camiseta azul avisou o outro gritando polícia. Informou que o réu José Francisco confessou o tráfico e apontou onde estavam as drogas, ou seja, embaixo de um papelão, em uma sacola preta apreenderam drogas divididas em porções) e no bolso dele havia dinheiro. O réu Evandro falou que era usuário, mas o acusado José Francisco informou que aquele era "olheiro". Não conhecia os réus anteriormente. Não tinha pessoas correndo. Há pontos de tráfico que usam rádios comunicadores, mas nesse local só gritam. Estavam com o distintivo de identificação de polícia. O réu Evandro confessou ser "olheiro" e usuário de drogas.

Cléber (policial), em juízo, afirmou que recebeu denúncia anônima com as características dos traficantes, que coincidiam com as dos réus. O acusado Evandro gritou polícia para avisar o corréu. Informou que o corréu confessou o tráfico, indicou onde estavam as drogas, bem como que o acusado Evandro era "olheiro". Nada foi apreendido em poder do réu Evandro. Não conhecia os réus. Nem todos os pontos de tráfico tem rádio comunicador e no caso em tela o acusado Evandro gritou polícia.

Os réus disseram que não conheciam os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-los indevidamente.

Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24). A quantidade de drogas apreendidas, que eram guardadas pelo acusado José Francisco (fls. 13/14 - 36 porções de maconha, 94 pedras de "crack" e 47 invólucros de cocaína) e a diversidade delas (maconha, "crack" e cocaína), que estavam divididas em invólucros, a apreensão de dinheiro com o mesmo, sendo que não provou a sua procedência e confessou na fase extrajudicial, a confissão informal, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Os policiais foram uníssonos no sentido de que após a denúncia anônima, abordaram o réu José, o qual confessou o tráfico e o réu Evandro que era "olheiro", e que apreenderam drogas em uma sacola no local indicado pelo primeiro.

O réu Evandro confessou na fase extrajudicial que colaborava como informante para o tráfico, trabalhando ao lado do acusado José Francisco, que era o responsável pelas drogas, o que foi corroborado pelas declarações do referido corréu e dos policiais, pelo que é caso de condenação.

As negativas judiciais dos réus estão isoladas nos autos, posto que José alegou que estava trabalhando para uma moradora, mas sequer soube informar o nome e Evandro que era usuário, estava no local para comprar drogas, porém não estava com dinheiro e nada provaram como lhes incumbia nos termos do art 156 do CPP, bem como suas versões são desmentidas pelos policiais.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que o réu José denunciado pela conduta de guardar.

A materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 16/21) e laudo

definitivo (fls. 229/231).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada aos acusados, que segundo consta dos autos José Francisco é reincidente (fls. 246 – proc. 1553-33.2017 – transitada em 09.10.17) , Evandro é primário (fls. 234/237) e possui um processo em andamento (fls. 235 – proc. 1510431-44.2021), que não pode ser considerado para quaisquer fins, em face do princípio do estado de inocência.

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que “a lei regulará a individualização da pena” e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

“O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)”.

Assim, a reincidência do acusado José Francisco será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o réu José Francisco, em razão da quantidade média de drogas (fls. 13/14 – 36 porções de maconha, 94 pedras de “crack” e 47 invólucros de cocaína), já que pequena quantidade é inferior a 100 porções, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e a confissão extrajudicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

“A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.ª Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: “ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal” (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no Resp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O réu José Francisco não faz jus à redução do art. 33, §4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente pelo art. 37 da Lei n.º 11.343/06 (fls. 246 – proc. 1553-33.2017 – transitada em 09.10.17), o que denota personalidade voltada para a prática de crimes relacionados ao tráfico, os quais são seu meio de vida, uma vez que sequer provou possuir ocupação lícita e, ainda, houve aumento da pena pela quantidade de drogas. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente (fls. 246 – proc. 1553-33.2017 – transitada em 09.10.17).

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 17.12.21, pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 16.04.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), bem como pela quantidade de drogas apreendidas, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o réu Evandro em 2 anos de reclusão e 300 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Inaplicável a redução do art. 33, § 4.º, uma vez que esta incide apenas em relação ao tráfico, previsto no art. 33.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, posto que o acusado Evandro é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, bem como diante do montante da pena (art. 33, §2.º, "c", do Código Penal) e que não se trata de crime hediondo ou equiparado, já que não elencado nos arts. 1.º e 2.º da Lei n.º 8.072 /90.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, e EVANDRO BARROMEIO à pena de 2 (DOIS) DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 300 (TREZENTOS) DIAS-

MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 37 da Lei n.º 11.343/06. Tendo em vista que o réu José Francisco foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 82/85), e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Quanto ao réu Evandro, considerando a redação do art. 44, §2.º, do Código Penal, e que a pena privativa de liberdade é superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS, consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, as quais são as mais adequadas para reprimir o crime, não sendo caso de aplicar multa, porque incompatível com a situação financeira do acusado. A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal), mas em razão da detração penal deverá ser abatido o tempo que ficou preso.

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa.

O acusado Evandro poderá recorrer em liberdade, porque é primário e após as substituições legais foram impostas apenas penas restritivas de direitos e multa. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas "ex lege" (Lei n.º 11.608/03) pelo acusado Evandro.

Sem custas pelo acusado José Francisco (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 13 e 225) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à sacola plástica de cor preta, apreendida (fls. 13), já periciada (fls. 140/141), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Desnecessário comunicar esta decisão ao Egrégio Tribunal, porque o H.C. já foi julgado, sendo denegada a ordem (fls. 263/270).

Transitada esta em julgado, lance-se o nome dos acusados no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 84) e providencie-se o necessário quanto ao perdimento do dinheiro, comunicando-se ao SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06), o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes, e intimação do acusado Evandro para o pagamento das custas processuais. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e façam-se as anotações e comunicações de praxe.
Diadema, 18 de abril de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA